

0001873-26.2011.8.26.0430

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUAN CASAGRANDE

Comarca: Paulo de Faria

Foro: Foro de Paulo de Faria

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 03/10/2022

... que o acusado se dedicava à prática do crime de tráfico. Ademais, o acusado ostenta antecedentes e é reincidente, o que indica uma dedicação habitual na prática de crimes, afastando a caracterização do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06). Sobre o assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paulo de Faria

Foro de Paulo de Faria

Vara Única

R. XV de Novembro, 809, Paulo de Faria - SP - cep 15490-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001873-26.2011.8.26.0430 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001873-26.2011.8.26.0430

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

ALOISIO MIGUEL FERREIRA

Juiz de Direito: Dr.LUAN CASAGRANDE

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de ALOISIO MIGUEL FERREIRA, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33, caput c/c artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia: Consta dos inclusos autos que, no dia 23 de março de 2010, por volta das 23hs00, no interior da penitenciária João Batista de Santana, situada na zona rural do município de Riolândia, nesta comarca de Paulo de Faria, ALOISIO MIGUEL FERREIRA, qualificado as fls. 239/240, vendeu e entregou a consumo no interior de estabelecimento prisional, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, duas porções contendo 1,45 g (um grama e quatrocentos e cinquenta miligramas) de cocaína, consoante o auto de exibição e apreensão de fls. 05 e o exame químico toxicológico de fls. 45. Segundo se apurou, nas circunstâncias descritas, o denunciado, que cumpria pena na penitenciária declinada, vendeu a terceira pessoa lá detida, identificada apenas por "Jordão", as drogas acima descritas. Embalou-as com um manuscrito que está a fl. 06, em que deu

conta do preço - R\$60,00 (sessenta reais) - do prazo e da conta em que deveriam ser depositados os valores, e remeteu tudo a outra cela, por intermédio de corda barbante conhecida por "tia". Sucede que agentes de segurança penitenciária que distribuíam remédios visualizaram o momento em que o "pacote" era transmitido de uma cela a outra e o interceptaram. O laudo de exame grafotécnico de fls. 230/231 confirmou que os escritos ali lançados no referido bilhete provieram do punho do denunciado. Evidente que o destino das drogas era o tráfico, em razão das circunstâncias da apreensão, com o concomitante encontro das condições da venda e instruções para o pagamento, bem como que este foi realizado nas dependências do estabelecimento prisional. Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência ALOÍSIO MIGUEL FERREIRA, qualificado às fls. 09/10, por infração ao artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11;343/2006, e requeiro autuada esta, seja o denunciado notificado para oferecer defesa prévia por escrito, dentro do prazo de dez dias, recebendo-se em seguida à denúncia, citando-o e interrogando-o, ouvindo-se o rol abaixo e prosseguindo-se nos demais atos, conforme procedimento estabelecido nos artigos 55 e seguintes da lei 11;343/06, até final sentença e condenação.

A denúncia foi recebida em 04/11/2013 (fl. 308).

O acusado foi notificado (fl. 450).

Apresentou defesa prévia (fls. 461-463).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 29 de setembro de 2022, foram ouvidas as testemunhas Rogério Damasceno Brito e Giovani Paschoto. O acusado não foi localizado, tendo sido decretada sua revelia.

O Ministério Público apresentou alegações orais, na qual afirmou estar comprovado a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual pleiteou a procedência da pretensão punitiva nos termos da denúncia, com reconhecimento de maus antecedentes, reincidência e fixação de regime fechado para cumprimento da pena.

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por ausência de elementos probatórios que demonstrem a conduta ilícita do acusado. Em caso de procedência, requereu a fixação da pena no mínimo legal e regime prisional mais brando.

É O RELATÓRIO

DECIDO

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06-07), Autos de Exibição e Apreensão (fl. 08), que comprova a apreensão da substância entorpecente e de dois bilhetes manuscritos, assentada (fls. 54/55) e Laudos Periciais (fls. 49-50, e 262-264).

No que tange à autoria calham as seguintes elucubrações.

A testemunha Rogério Damasceno Brito, agente penitenciário, narrou que no dia dos fatos estava no pátio da unidade e percebeu que os detentos estavam passando a "tia", que é uma corda improvisada que é passada de uma cela para outra, onde são mandados mantimentos, alimentação, entre outros gêneros. Disse que ao ver que estavam passando a corda, realizou a interceptação e constatou que na mesma havia um invólucro contendo supostamente substância entorpecente. Aduziu que fez a apreensão e encaminhou ao chefe de plantão que elaborou o comunicado de evento e encaminhou para a polícia civil. Questionado, confirmou que a "tia" estava sendo passada de uma janela para a outra. Afirmou que não conseguiu identificar quem estava passando e quem estava recebendo a substância. Aduziu que provavelmente o acusado foi coagido a assumir a autoria do ilícito, pois alguém da cela tem que assumir a autoria do ilícito. Questionado pela defesa, disse não recordar quantos detentos havia na cela. Ao ser questionado, confirmou que havia um bilhete apreendido junto com a substância. Por fim, ao ser questionado pelo juízo, aduziu que no presente caso, viu ninguém sendo coagido no interior da cela onde o acusado estava.

A testemunha Giovani Paschoto, agente penitenciário, em sede policial, declarou na data do ocorrido estava junto com o agente Rogério Damasceno quando este encontrou um pacote que continha em seu interior dois invólucros com uma substância branca, que aparentava ser cocaína, além de dois bilhetes manuscritos. Especificou que tal

pacote estava amarrado em uma corda de barbante vulgarmente conhecida como "tia". Informou que o material encontrado foi apreendido e encaminhado para o diretor do turno. (fl. 55). Em juízo, em razão do decurso do tempo, afirmou que não recorda dos fatos, mas afirmou que os fatos existiram, e disse que foram apreendidas substâncias e também bilhetes.

Destaco, de pronto, que os depoimentos dos agentes penitenciários retro transcritos se revestem de inequívoca validade, eis que colhidos em juízo, sob o manto do princípio constitucional do contraditório e do devido processo legal. Ademais, os agentes não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado no exercício das funções. Assim, cumpre dar validade aos depoimentos das testemunhas de acusação inquiridas no curso da instrução criminal. Essa é a orientação que se colhe da jurisprudência, como se infere da leitura da ementa do aresto que segue, in verbis:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016);

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS PROVA SUFICIÊNCIA Materialidade e autoria comprovadas Apelante flagrado no momento em que entregava estupefaciente para consumo do corréu, ambos custodiados em Penitenciária Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes Provas incriminatórias consistentes Testemunha arrolada pela Defesa que não infirmou as responsabilidades penais dos acusados - DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS VALIDADE Os testemunhos dos agentes penitenciários têm validade como quaisquer outros Depoimentos coerentes Condenação mantida Crimes configurados - Sentença condenatória mantida RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. (TJ-SP - APR: 00105897920078260269 SP 0010589-79.2007.8.26.0269, Relator: Amado de Faria, Data de Julgamento: 15/12/2011, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/12/2011);

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES DENTRO DE UNIDADE PRISIONAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS - VALIDADE - FARTA PROVA TESTEMUNHAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Estando provadas a materialidade e a autoria delitiva, verificando-se, ainda, o intuito de tráfico da droga apreendida dentro da unidade prisional, é devida a condenação do réu; 2. Os testemunhos de agentes penitenciários, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los; 3. Recurso não provido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 3690106 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 06/04/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2016);

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Prova inequívoca de que a ré tentou ingressar com maconha no estabelecimento prisional. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. O depoimento dos agentes da lei tem o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um decreto condenatório. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. Isentar-se o réu da multa prevista também é medida descabida, vez que não cabe ao julgador deixar de aplicar imposição legal. No juízo da execução é que a miserabilidade do condenado pode ser examinada para fim de ser concedida a isenção ou o parcelamento. Apelo improvido. (TJ-RS - APL: 70069660983 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 24/08/2016, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2016).

Na presente situação, os agentes penitenciários que participaram da ocorrência prestaram depoimento em juízo. O agente penitenciário Rogério Damasceno Brito, aduziu que estava no pátio da unidade prisional, quando flagrou que entre as celas estava sendo passada a "tia", que corresponde a uma corda passada pelos detentos entre as celas, por onde transportam objetos lícitos e ilícitos. Disse que ao ver o uso da corda, realizou a apreensão da mesma e narrou que foi localizada substância entorpecentes e bilhetes. O depoente aduziu que não visualizou quem estava passando e quem estava recebendo a substância, e que às vezes acontece de alguém ser coagido a assumir a responsabilidade, mas ao ser questionado, confirmou que não viu qualquer tipo de coação levada a efeito no interior da cela. Por sua vez, o agente penitenciário Giovani Paschoto, ao ser ouvido em juízo, confirmou não ter mais lembrança dos fatos, dado o lapso de tempo que passou até então, todavia, em sede policial, afirmou que no dia dos fatos, quando da ocorrência, foi encontrado um pacote que continha em seu interior dois invólucros com uma substância branca, que aparentava ser cocaína, além de dois bilhetes manuscritos.

Aliado ao depoimento prestado pelos agentes penitenciários, foram realizados diversas perícias grafotécnicas de diversas pessoas para aferir quem teria redigido os bilhetes que foram apreendidos, conforme se verifica dos laudos periciais acostados em fls. 184-188, 196-198 e 262-264. Ao realizar o exame grafotécnico dos materiais coletados e enviados de punho do acusado, em confronto com os lançamentos contidos nos bilhetes, peças de exame, o perito encontrou afinidades suficientes para identificar com segurança que os lançamentos gráficos contidos na peça de exame provieram do punho do acusado:

Diante dos elementos probatórios encartados aos autos, em especial pela prova produzida sob o crivo do contraditório, entendo que restou devidamente comprovado que o acusado estava na posse de substância vulgarmente conhecida como cocaína, que causa dependência física e psíquica, e que tentou passar entre as celas da unidade, cobrando o valor de R\$ 60,00 (sessenta reais) pelas porções, conforme se afere de fls. 09 dos autos. Ademais, tendo em vista a quantidade e a forma como a droga estava acondicionada, bem como, pelos bilhetes encontrados - que provieram de punho do acusado - descreverem a forma de pagamento, entendo que a substância destinava-se à comercialização, mostrando-se o acervo probatório idôneo, seguro e apto a comprovar o envolvimento do acusado na prática do crime, que com sua conduta, de portar/vender o entorpecente, incorreu na prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sabe-se que o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não sendo exigida a venda de entorpecente a terceiro para que ocorra a consumação deste delito. Nesse sentido, entende a jurisprudência: Tráfico de entorpecentes. Réu que, submetido à revista para entrar em penitenciária a fim de visitar seu irmão, é surpreendido na posse de uma porção de maconha, com peso aproximado de 6,76 gramas, escondida em sua cueca. Prova oral hábil. Palavras dos agentes penitenciários coerentes e harmônicas. Circunstâncias da prisão evidenciando que a droga seria entregue para o consumo de terceiros e impossibilitando a desclassificação da conduta para o crime do artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Versão do réu isolada e que não convence. Condenação de rigor. Causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, bem reconhecida. Penas que

não comportam reparo e já beneficiaram o acusado com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, inviável. Regime fechado necessário. Apelo improvido. (TJ-SP - APL: 00013310520158260224 SP 0001331-05.2015.8.26.0224, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 08/02/2017, 7ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/02/2017);

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE MAJORADO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006) SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS AGENTES PENITENCIÁRIAS COM ESPECIAL RELEVÂNCIA JÁ QUE EMBASADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APREENSÃO DE CERCA DE QUARENTA E CINCO GRAMAS DE "MACONHA" ALOCADAS NO INTERIOR DA CAVIDADE VAGINAL DA INSURGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO DEMONSTRAM O DOLO DE TRAFICÂNCIA NA CONDUTA PERPETRADA PELA APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª C. Criminal - 0039437-24.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos - J. 25.05.2020). (TJ-PR - APL: 00394372420198160014 PR 0039437-24.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/05/2020).

Considerando que o crime ocorreu dentro de estabelecimento prisional, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é maior, já que denota uma maior audácia na medida em que nem mesmo a restrição de sua liberdade foi capaz de frear seu ímpeto criminoso, já que continua a cometer crimes mesmo já estando a cumprir sanção penal. Assim, entendo por bem majorar a pena do acusado em metade, o que se mostra proporcional e razoável à gravidade de sua conduta, diante de seu total desrespeito pela figura do Estado. Assim entende a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RESOLUÇÃO 890/2019. VARA DE INQUÉRITOS. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª VARA CRIMINAL DE CONTAGEM. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E PRECLUSÃO. INQUIRIRÇÃO DAS TESTEMUNHAS PELO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA DE TRÁFICO. CONSUMAÇÃO COM O TRANSPORTE. FRAÇÃO DO ART. 40, III DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO. CUSTAS. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 1. A Resolução 890/2019 criou nova Vara em Contagem, competente para análise de feitos de Violência Doméstica e Familiar contra mulher e de Inquéritos. Cessada a fase das investigações preliminares e não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecida a denúncia, a causa deve ser distribuída dentre as varas criminais da comarca. 2. O TJMG tem atribuição para dispor sobre a organização judiciária no Estado, buscando maior efetividade e celeridade no julgamento das demandas. 3. Inexiste irregularidade ou perplexidade no encaminhamento do feito para distribuição entre varas criminais, igualmente competentes, pois a Vara de Inquéritos tem competência delimitada pelo oferecimento da denúncia, em casos que não se tratem de violência doméstica. 4. A inquirição das testemunhas diretamente pelo juiz e antes das partes constitui nulidade de natureza relativa, que reclama a prova do prejuízo para ser declarada. Ausente prejuízo, não se declara a nulidade. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, impõe-se a manutenção da condenação da acusada pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, revelando-se incabível a absolvição. 6. Tratando-se o tráfico de crime de conteúdo múltiplo e forma variada, o transporte da droga consuma o delito, ainda que o fim visado pela ré fosse entregá-la a terceiro, dentro da Penitenciária, e não tenha alcançado seu objetivo final, que seria mero exaurimento da conduta. 7. A aplicação de fração superior à mínima, na causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/2006, se justifica em virtude de a acusada ter ingressado em Penitenciária de Segurança Máxima, denotando maior destemor de sua conduta, todavia, a fração intermediária de 1/2, mostra-se mais proporcional, suficiente e necessária, não só a reprovação do crime, mas visando também à ressocialização da agente, do que a máxima de 2/3. 8. Presume-se a hipossuficiência da agente

defendida pela Defensoria Pública, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. (TJ-MG - APR: 10079190180889001 Contagem, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021). Considerando que o crime ocorreu dentro de estabelecimento prisional, o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é maior, o que denota uma maior audácia deste, uma vez que nem mesmo a restrição de sua liberdade foi capaz de frear seu ímpeto criminoso, já que continua a cometer crimes mesmo já estando a cumprir sanção penal. Assim, entendo por bem majorar a pena do acusado em metade, o que se mostra proporcional e razoável à gravidade de sua conduta, diante de seu total desrespeito pela figura do Estado. Assim entende a jurisprudência: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RESOLUÇÃO 890/2019. VARA DE INQUÉRITOS. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA COM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª VARA CRIMINAL DE CONTAGEM. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE E PRECLUSÃO. INQUIRIRÇÃO DAS TESTEMUNHAS PELO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE JUSTIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA DE TRÁFICO. CONSUMAÇÃO COM O TRANSPORTE. FRAÇÃO DO ART. 40, III DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO. CUSTAS. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 1. A Resolução 890/2019 criou nova Vara em Contagem, competente para análise de feitos de Violência Doméstica e Familiar contra mulher e de Inquéritos. Cessada a fase das investigações preliminares e não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, oferecida a denúncia, a causa deve ser distribuída dentre as varas criminais da comarca. 2. O TJMG tem atribuição para dispor sobre a organização judiciária no Estado, buscando maior efetividade e celeridade no julgamento das demandas. 3. Inexiste irregularidade ou perplexidade no encaminhamento do feito para distribuição entre varas criminais, igualmente competentes, pois a Vara de Inquéritos tem competência delimitada pelo oferecimento da denúncia, em casos que não se tratem de violência doméstica. 4. A inquirição das testemunhas diretamente pelo juiz e antes das partes constitui nulidade de natureza relativa, que reclama a prova do prejuízo para ser declarada. Ausente prejuízo, não se declara a nulidade. 5. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, impõe-se a manutenção da condenação da acusada pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, revelando-se incabível a absolvição. 6. Tratando-se o tráfico de crime de conteúdo múltiplo e forma variada, o transporte da droga consome o delito, ainda que o fim visado pela ré fosse entregá-la a terceiro, dentro da Penitenciária, e não tenha alcançado seu objetivo final, que seria mero exaurimento da conduta. 7. A aplicação de fração superior à mínima, na causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/2006, se justifica em virtude de a acusada ter ingressado em Penitenciária de Segurança Máxima, denotando maior destemor de sua conduta, todavia, a fração intermediária de 1/2, mostra-se mais proporcional, suficiente e necessária, não só a reprovação do crime, mas visando também à ressocialização da agente, do que a máxima de 2/3. 8. Presume-se a hipossuficiência da agente defendida pela Defensoria Pública, fazendo jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. (TJ-MG - APR: 10079190180889001 Contagem, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 03/02/2021, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/02/2021).

Por sua vez, a Defesa não conseguiu demonstrar a qualquer elemento de prova caracterizador de causa excludente da ilicitude ou culpabilidade. Ademais, considerando a quantidade da substância apreendida e a forma como estava acondicionada, entendo que a mesma se destinava à comercialização. Nesse sentido: APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria comprovadas pela apreensão das substâncias entorpecentes (10 tijolinhos de maconha, pesando 27,30 gramas), em porções pronta para a venda, dispensadas pelo réu quando do fato, em local de tráfico, quantidade incompatível com o mero consumo próprio e com as condições econômicas do réu, que não demonstrou exercer qualquer atividade lícita, evidenciando a destinação da droga ao tráfico ilícito. (...) A circunstância de ser o acusado, também, usuário de drogas não afasta a prática do delito. Desnecessária, nesse contexto, prova presencial da

mercancia. O regime inicial, em face da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, reconhecida pelo STF, deve observar o disposto no art. 33 do CP, estando, na espécie, justificado o regime fechado, na forma do art. 33, § 2º, \a\, do CP. Apelo improvido. (TJ-RS - ACR: 70049990120 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 15/12/2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2016);

Apelação criminal – Tráfico de drogas– Sentença condenatória. Recurso defensivo – Pleito de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de fixação da pena-base no mínimo legal, em face da inexistência de maus antecedentes, bem como de aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e, finalmente, de fixação de regime inicial aberto, considerando-se o período em que ficou preso provisoriamente. Materialidade e autoria comprovadas- Prisão em flagrante delito. Apreensão de 27 invólucros de maconha com o réu (peso: 26,27 gramas). (...) Não aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, eis que a quantidade da droga e as circunstâncias evidenciam que o réu se dedicava à atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido, por ser o único compatível com o delito em tela. (...). (TJ-SP - APL: 00095761320148260071 SP 0009576-13.2014.8.26.0071, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 27/10/2016, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/10/2016).

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria do crime, ausentes causas da exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a procedência da denúncia é o caminho imperativo a ser trilhado.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição). Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei nº 11.343/06, “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42).

No caso, o delito é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

DOSIMETRIA

1ª FASE. PENA BASE

Na primeira fase, verifica-se que o acusado possui antecedentes, pois devidamente condenado nos autos dos processos números 0939344-05.1996.8.26.0001 (001.96.939344-8), conforme se verifica de certidão de fls. 558-560. Inexistem informações nos autos sobre sua conduta social e personalidade. Os motivos e circunstâncias são inerentes ao crime. Por sua vez, a natureza e quantidade das drogas corroboram a caracterização do tráfico, devendo ser valoradas na terceira fase e para a fixação do regime.

Diante do exposto, considerando os antecedentes do acusado, a pena-base deve se afastar do mínimo legal. Assim, exaspero a pena em 1/6, passando a dosá-la em 5 anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

2ª FASE. PENA INTERMEDIÁRIA

Inexistem circunstâncias atenuantes. Incide a circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, do código Penal, na medida em que o acusado foi condenado pela prática de crime, por sentença transitada em julgado, nos autos

do processo nº 0093225-51.2005.8.26.0050 (050.05.093225-0) a menos de cinco anos da prática do crime pelo qual é julgado nesse momento. Diante disso, agravo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa.

3ª FASE. PENA DEFINITIVA

Na terceira fase, as circunstâncias do fato, ou seja, a quantidade de droga encontrada, a forma em que estava sendo distribuída e os bilhetes com escritos provenientes do próprio punho do acusado que acompanhavam a substância, com o valor que deveria ser pago pelo entorpecente que estava sendo repassado, bem como, a prática do crime no interior de unidade prisional, indicam que o acusado se dedicava à prática do crime de tráfico. Ademais, o acusado ostenta antecedentes e é reincidente, o que indica uma dedicação habitual na prática de crimes, afastando a caracterização do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06). Sobre o assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU QUE É REINCIDENTE E OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. (...) Assim, tendo em vista que o incremento de 2 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa foi indevido, a pena intermediária deve ser redimensionada para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, pena que deve ser mantida na terceira etapa, vez que não incide, na espécie, a minorante no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, não preenchendo, portanto, os requisitos legais. 5. Deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, II, III, do Código Penal, vez que a pena fixada é superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº 0117554-52.2016.8.06.0001, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 23 de julho de 2019 DESEMBARGADOR MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator (TJ-CE - APL: 01175545220168060001 CE 0117554-52.2016.8.06.0001, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 23/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/07/2019);

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, "CAPUT", DA LEI Nº 11.343/06)- SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) - PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO ACOLHIMENTO - NÃO PREENCHIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS - RÉU OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E É REINCIDENTE, ALÉM DE EXISTIREM DENÚNCIAS SOBRE O SEU ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO - DOSIMETRIA MANTIDA - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0007170-40.2018.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: Desembargador Carvílio da Silveira Filho - J. 31.08.2020) (TJ-PR - APL: 00071704020188160044 PR 0007170-40.2018.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Desembargador Carvílio da Silveira Filho, Data de Julgamento: 31/08/2020, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/09/2020);

É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos são elementos que, associados às circunstâncias do caso concreto, evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no AREsp 1624502/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020);

Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência

da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. (AgRg no HC 638.977/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021); In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas (02 tabletes e 28 porções menores de maconha, 13 pinos de cocaína e 56 porções de crack - e-STJ fl. 31), mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. (AgRg no HC 631.293/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021); As instâncias ordinárias, dentro do seu livre convencimento motivado, consideraram, com base nos elementos concretos constantes dos autos, que as circunstâncias em que perpetrado o delito de tráfico de drogas não se compatibilizariam com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao narcotráfico, o que afasta a pretendida incidência do redutor descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (AgRg nos EDcl no HC 611.066/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).

Presente a causa de aumento de 1/6 a 2/3 referente à prática de tráfico nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional (art. 40, III, da Lei 11.343/06). Como o acusado foi flagrado na posse de droga dentro da unidade prisional (e não nas imediações), sua conduta se torna mais reprovável, motivo pelo qual se justifica a aplicação da fração de aumento em metade (1/2), o que resulta em 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão e o pagamento de 1020 dias-multa, pena que torno definitiva.

VALOR DO DIA MULTA

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Cabe reconhecer que o delito cometido é equiparado a hediondo (art. 2º da Lei 8.072/90 e Súmula 510 do STJ), mas a hediondez por si só não justifica a imposição de regime fechado (Tema 972 da repercussão geral do STF), surtindo efeitos apenas na esfera de execução da pena. Pela presença da gravidade concreta da conduta, dada pelos elementos expostos na terceira fase da dosimetria, em especial, pelo crime ter ocorrido dentro do estabelecimento prisional, e considerando a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, deve ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, na forma do art. 33, §2º, a, do Código Penal, Súmula 269 do STJ (analogicamente) e Súmula 719 do STF.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Em razão do montante da pena (superior a 4 anos), incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena (arts. 44 e 77 do CP), diante do não preenchimento dos requisitos objetivos previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DETRAÇÃO (art. 387, §§ 1º e 2º do CPP)

O acusado não se encontra recluso, inexistindo motivos para que, no presente momento, seja determinada a restrição cautelar de sua liberdade em razão do

presente feito. Considerando que não respondeu ao processo em reclusão, não há que se falar na incidência do quanto disposto no art. 387, §2º, do CPP.

VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO

Deixo, ademais, de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por não haver instrução e pedido a respeito de eventuais danos sofridos. A esse respeito, cito a lição de Guilherme de Souza Nucci: "Admitindo-se que o Magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los" (Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed., 2008, p. 691).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar ALOISIO MIGUEL FERREIRA à pena de 10 (dez) anos 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, a ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, e ao pagamento de 1.020 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c. c. art. 40, III, da Lei 11.343/06 e art. 61, I, do Código Penal. Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça. Com o trânsito em julgado, certifique-se e expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 398 das NSCGJ), o mandado de prisão e, após, seu cumprimento, a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ; bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

P.I.C.

Paulo de Faria, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA